

TEMA 4: Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo

Las fuentes del Derecho Administrativo.

Tradicionalmente se distinguen fuentes del derecho en sentido material y fuentes del derecho en sentido formal.

En sentido material, entendemos por fuente del derecho la institución e instituciones que tienen la potestad atribuida de crear normas jurídicas. P.ej. Cortes Generales, Ayuntamiento.

En sentido formal, entendemos por fuente del derecho la concreción del ejercicio de esa potestad normativa, es decir la forma que adopta la norma en su concreción. P.ej. Ley, Real Decreto, etc.

Fuentes primarias, ordenadas jerárquicamente:

- La Constitución.
- Leyes orgánicas y ordinarias, y disposiciones del Gobierno con valor de ley.
- Reglamentos y disposiciones administrativas.

Fuentes subsidiarias:

- Costumbre
- Principios generales del derecho.

Otras fuentes:

- Tratados internacionales.
- Derecho Comunitario.

La jerarquía de las fuentes.

Un sistema de fuentes precisa la existencia de unos principios sobre las mismas fuentes, que las ordenen o jerarquicen, asignando a cada su posición dentro del conjunto. Esta función la cumplen los principios de **jerarquía normativa** y el de **competencia**.

Según el primero de ellos, recogido en el artículo 9.3 Constitución, la norma superior deroga a la inferior y la inferior es nula cuando contradice la superior.

El principio de **competencia** significa la atribución a un órgano concreto de la potestad de regular materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás órganos.

Estas normas son complementan con el **principio cronológico**, según el cual la norma posterior deroga a la norma anterior.

Los Tratados Internacionales, es decir, los acuerdos que el Estado español celebra con otros Estados, también son fuente del Derecho interno una vez publicados oficialmente en España. Un aspecto importante lo constituye sus efectos: los tratados modifican las leyes que les son contrarias, pero no a la inversa, es decir, no son modificables por leyes posteriores sino que *“sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”* (artículo 96.1 CE).

No obstante, al no intervenir el Parlamento sino el Ejecutivo en la negociación y firma de los tratados, la Constitución establece un sistema de control (93 a 96 CE). Si el tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución será precisa la previa reforma constitucional, pudiéndose requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Será precisa la autorización previa de las Cortes, en determinados casos.

Debido a la integración de España en las Comunidades Europeas, debemos aludir también al **Derecho Comunitario**, en el que podemos distinguir entre el Derecho Comunitario originario, integrado por los Tratados Internacionales (p.ej. Tratado de Roma sobre la Comunidad Económica Europea, Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, o el propio Tratado de Adhesión de España) y el Derecho Comunitario Derivado.

Este último se integra por una serie de normas emanadas de las Instituciones comunitarias (Comisión Europea, Parlamento Europeo), con vigencia directa e inmediata en el Derecho español, se define bajo el principio de primacía del Derecho Comunitario. Estas normas son

- Reglamentos, con alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- Directivas, que sólo obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a los mismos la elección de la forma y los medios.
- Decisión, obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios.
- Recomendaciones y los Dictámenes, se señala que no serán vinculantes.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades ha ido definiendo las condiciones y requisitos que deben reunir las disposiciones de los tratados que tendrán esta eficacia normativa directa y cuáles carecerán de ella.

La Ley

Las leyes son aquellas normas de origen parlamentario, subordinadas a la Constitución, e irresistibles e indiscutibles para los operadores jurídicos.

Dentro de las leyes parlamentarias, además de las leyes ordinarias, que se aprueban por el procedimiento habitual y mayoría simple,

El procedimiento legislativo se regula en el Título III, Capítulo II de la Constitución española de 1978 (artículos del 81 al 92).

El procedimiento se inicia con la iniciativa o presentación de proyectos de ley, presentados por el Gobierno de la Nación, o bien proposiciones de ley si son presentadas por los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado o por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

También es posible la iniciativa legislativa popular (LO 3/1984, de 28 de marzo), con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (artículo 87.3 de la Constitución).

Una vez ejercida la iniciativa, si se trata de una proposición de ley, la Mesa de la Cámara la remitirá al Gobierno para que pueda oponerse a su tramitación, para pasar después al Pleno de la Cámara, que se pronunciará sobre su toma en consideración. Este trámite no se aplica a los proyectos de ley.

Tras el trámite parlamentario (con posibles incidencias, como la actuación de las Comisiones o el debate sobre las enmiendas) Para que los proyectos sean aprobados basta la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, cualquiera que sea el número de abstenciones, salvo que la Constitución exija una mayoría cualificada.

Si el Senado ha introducido enmiendas o ha puesto su veto el proyecto se devuelve al Congreso para su nueva consideración. Si se trata de enmiendas, el Congreso se pronunciará sobre ellas, admitiéndolas o no por mayoría simple. Si se trata de veto, el proyecto habrá de someterse a ratificación, que requerirá mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses, mayoría simple.

El procedimiento legislativo concluye con la sanción por parte del Rey, en cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de 1978 que señala que “el Rey sancionará, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”, que deberá hacerse en el BOE, según establece el artículo 2.1 Código Civil.

Leyes orgánicas.

La Constitución de 1978 ha introducido la categoría de leyes orgánicas. Estas leyes se refieren a materias de especial trascendencia y requieren mayoría absoluta del Congreso. Se refieren “al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución” (artículo 81 Constitución).

Leyes autonómicas.

También son leyes parlamentarias las leyes de las Comunidades Autónomas, es decir, las normas que aprueben sus órganos legislativos sobre materias que tiene atribuidas y sobre las cuales tiene el Tribunal Constitucional el control de su constitucionalidad. Están subordinadas a la Constitución y a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Su relación con las leyes del Estado viene dado por el principio de competencia, en lugar del principio de jerarquía, es decir tienen el mismo rango.

Las Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo.

El Gobierno tiene atribuida la facultad de dictar normas con rango de ley bajo las fórmulas de decreto-ley y de decreto legislativo, también denominadas “normas con fuerza de ley”.

Decretos-Leyes: En “caso de extraordinaria y urgente necesidad” y no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general. Deberá ser ratificado por el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

Decretos legislativos: Se trata de legislación “delegada” (art 85 CE). Las Cortes Generales, mediante leyes de delegación o de autorización, normalmente en ámbitos muy técnicos, pueden delegar en el Gobierno la facultad de dictar una Ley de acuerdo con unos principios o bases previamente establecidos o bien autorizarle a refundir el contenido de varias leyes en un único texto que se materializa en la aprobación de textos refundidos. El ejemplo más cercano lo tenemos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La delegación puede contener cualquier materia, excepto la que deba ser objeto de regulación por ley orgánica. La delegación ha de hacerse de forma expresa, con fijación del plazo para su ejercicio, y precisa, de forma que las bases han de delimitar con precisión el objeto y alcance de la delegación, que no puede incluir ni modificar las bases, ni dictar normas con carácter retroactivo.

Las autorizaciones para refundir textos legales deben determinar si la delegación se refiere a la mera formulación de un texto único o si incluye el regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

El Reglamento: concepto, clases y límites.

Por Reglamento se entiende toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una Administración Pública y supone el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Al tener rango inferior a la ley se entiende que, en primer lugar, que aunque sea posterior el reglamento no puede derogar a la ley y, por el contrario, toda norma con rango de ley puede derogar un reglamento. También significa que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria en el sentido de que la ley puede regular cualquier materia regulada anteriormente por el reglamento.

no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

Esta posición ordinal de la ley y el reglamento se expresa en el principio de reserva de ley.

Este principio tiene dos manifestaciones:

- Reserva material de ley, que comprende las materias para las cuales exige la Constitución una regulación por norma con rango de ley y que, por tanto, no pueden ser reguladas por normas reglamentarias aunque no lo haga la ley.
- Reserva formal de ley, que significa que cualquier materia, cuando es regulada por ley ya no puede serlo por un reglamento.

El art. 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPC) es muy estricto en este sentido:

“Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer

penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.”

La doctrina señala la diferencia entre reglamento y acto administrativo general (que también puede ir dirigido a un conjunto de ciudadanos): El reglamento es una norma y como tal no se agota por una sola aplicación; por el contrario, el acto administrativo general se extingue en una sola aplicación, por numeroso que sea el grupo al que va dirigido.

Clases

Tradicionalmente se han distinguido diversas categorías de reglamentos:

a) Por su relación con la Ley:

Reglamentos ejecutivos o de desarrollo de normas legales, que desarrollan la legislación.

Reglamentos independientes, no traen causa de una Ley previa, no actúan por mandato legal sino que, en virtud de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, éste trata de regular materias de las que La Ley no ha regulado. Evidentemente, nunca podrían regular materias reservadas a Ley.

- Reglamentos autónomos, con sujeción a la ley y cierta dependencia de la misma, pero sin desarrollar y ejecutar sus preceptos. Es el caso del planeamiento urbanístico, donde algunos aspectos la Ley remite de plano al ámbito reglamentario, que contiene la regulación completa de cierta materia, sector o realidad.

- Reglamentos de necesidad, que responden a circunstancias excepcionales y transitorias. (Estados de excepción, p.ej.) No tienen carácter estable, es decir, su vigencia no es indefinida.

b) Por razón de la materia

Podemos distinguir entre reglamentos orgánicos y reglamentos jurídicos.

- Reglamentos organizativos son los que regulan la organización administrativa y los que se dictan en el ámbito de la relación existente entre la Administración y determinados ciudadanos (p.ej. los funcionarios).

- Reglamentos jurídicos son los que establecen derechos o deberes en el ámbito de la relación entre la Administración y el conjunto de los ciudadanos.

c) Por razón de la Administración que los dicta:

- Estatales: los de mayor jerarquía son los dictados por el Gobierno, que revisten la forma de “Real Decreto”. Subordinados a éstos y a las Ordenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, están los Reglamentos de los Ministros, con la forma de Orden Ministerial, dictados en las materias propias de su Departamento, y los reglamentos de las Autoridades inferiores, que revestirán la forma de Resolución, Instrucción o Circular.
- Autonómicos: se denominan de la misma forma que los anteriores: Decretos, del Consejo de Gobierno o Gobierno de la Comunidad Autónoma; Ordenes de los Consejeros.
- Locales, Distinguimos entre el Reglamento orgánico de cada Entidad, por el que ésta se autoorganiza y las Ordenanzas locales, que son normas de eficacia externa, en todo caso competencia del Pleno de la Entidad. Se discute si los Bandos, que el Alcalde puede dictar en materias de su competencia, tienen naturaleza de normas o son actos administrativos de carácter general.

Procedimiento de elaboración de los reglamentos

El procedimiento para ejercitar la potestad reglamentaria está regulado en la Ley 39/2015 (arts. 128 y siguientes), que ha introducido como requisito que se respeten los principios de buena regulación, es decir, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Además, cuando afecte a los gastos o ingresos públicos, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Como novedades de la Ley 39/2015, tenemos además que:

- Anualmente se hará público un **Plan Normativo**, en el Portal de la Transparencia, que contendrá las iniciativas que pretendan llevarse a aprobación en el año siguiente.
- Se deberá garantizar la **participación** de los ciudadanos en su elaboración a través de trámites de consulta, audiencia e información públicas.

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento (49 LBRL)::

- a) Aprobación inicial por el Pleno.
- b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Su aprobación es por mayoría simple. Se requerirá la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación cuando se trate del Reglamento orgánico de la Corporación y los planes y ordenanzas urbanísticos.

Eficacia del Reglamento.

El reglamento es eficaz a partir de su publicación y entrará en vigor el día que así lo establezca o de no guardar silencio, a los 20 días de su publicación (norma general del Código Civil). La publicación de las ordenanzas locales tiene lugar en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días desde que el mismo sea recibido por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales .

El reglamento puede ser derogado por la misma autoridad que lo dictó, que también puede proceder a su modificación parcial. Lo que no se puede hacer ni la autoridad que lo dictó ni otra superior es derogar el reglamento para un caso concreto (regla de inderogabilidad singular de los reglamentos, art. 37 LPAC) por la que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

Otras fuentes del Derecho Administrativo

La costumbre y los precedentes o prácticas administrativas.

En Derecho español, la regulación general del artículo 1 del Código Civil reconoce la costumbre como fuente del Derecho, en defecto de ley aplicable. La costumbre como fuente jurídica se caracteriza por dos elementos de origen social: un uso o comportamiento reiterado y uniforme y la convicción de su obligatoriedad jurídica.

Tiene un valor muy limitado de fuente del Derecho administrativo, caracterizado por el principio de legalidad y por tanto de normas escritas, pero en algunas materias las leyes administrativas lo reconocen expresamente: el régimen municipal de Concejo abierto; el régimen de aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales o la organización y funcionamiento de los Jurados y Tribunales de riego, como el Tribunal de las Aguas de Valencia.

Por su parte, la práctica supone una reiteración en la aplicación de un determinado criterio en varios casos anteriores, mientras que el precedente puede ser simplemente la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto, análogo a otro pendiente de resolución. Lo trascendente es que se trata de reglas deducidas del comportamiento de la Administración sin intervención de los administrados, cuya conducta es aquí irrelevante.

Tanto las prácticas como los precedentes administrativos tienen una importancia real en la vida administrativa, hasta el punto que la Administración está obligada a motivar aquellas resoluciones “*que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes*”. Por ello, la Administración puede desvincularse de su práctica o precedente al resolver motivando su decisión, pero ello exige la exposición de razones objetivas que expliquen y justifiquen el cambio de conducta, para evitar caer en la arbitrariedad y contravenir el principio de igualdad.

Principios generales del derecho

La Constitución recoge un buen número de principios que los que se entienden por principios generales del Derecho, como la regulación de derechos fundamentales y libertades públicas o los principios de irretroactividad, de igualdad, de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, etc.

El artículo 1.4 Código Civil señala que “los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”.

Jurisprudencia

El Código Civil también menciona a la jurisprudencia, aún sin reconocerla directamente el valor de fuente del Derecho, al establecer que “complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”.

Es decir, para que exista Jurisprudencia deben existir al menos 2 sentencias del Tribunal Supremo, en el mismo sentido, o bien que el propio Tribunal Supremo haya fijado su posición como “doctrina legal” a través de un recurso de casación.

Por otro lado, aún más importante es la doctrina del Tribunal Constitucional, por encima del propio Tribunal Supremo. que en sus Sentencias es el supremo intérprete de la Constitución y el único que puede enjuiciar la constitucionalidad de las Leyes.

Además, existen además otras dos fuentes de doctrina jurisprudencial que son fruto de nuestra integración europea: de una parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, de otro lado, son vinculantes también para los Tribunales y autoridades españolas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.